

1500075-93.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... em decorrência do crime de tráfico de drogas)(fls. 37/60). Em razão dos fortes indícios do envolvimento recente de CLÁUDIO na prática do tráfico de drogas e da suspeita que ele prosseguia nesse comércio espúrio após a prisão de Vitor Anacleto, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar em sua casa, expedido nos autos nº 1500142-70.2022.8.26.0482, no dia 19 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500075-93.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500075-93.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA, qualificado à fl. 05, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de janeiro de 2022, no período matutino, na Rua Antônio de Freitas Cardoso, nº 14, Jardim Marisa, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado guardava e tinha em depósito droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 2,12g (duas gramas e doze centigramas - lacre nº 0026898), conforme boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação provisório de fls. 11/13 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 110/112. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de crack acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a guardá-las e mantê-las em depósito em sua

residência com vistas a comercializá-las ilicitamente. Inicialmente, cumpre registrar que os policiais militares receberam denúncias anônimas indicando a traficância de drogas no bairro Jardim Brasília e montaram ponto de observação, em datas diversas, visando aferir a veracidade das informações recebidas. Em dada oportunidade, constatarem a movimentação típica de comercialização de substâncias de entorpecentes, com a intermediação do denunciado CLÁUDIO, em frente à residência de Vitor Anacleto Martins da Silva¹(Vitor Anacleto Martins da Silva foi preso em flagrante, no dia 04/01/2022, nos autos nº 1500026-52.2022.8.26.0583 em decorrência do crime de tráfico de drogas)(fls. 37/60). Em razão dos fortes indícios do envolvimento recente de CLÁUDIO na prática do tráfico de drogas e da suspeita que ele prosseguia nesse comércio espúrio após a prisão de Vitor Anacleto, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar em sua casa, expedido nos autos nº 1500142-70.2022.8.26.0482, no dia 19 de janeiro de 2022 (fl. 06). Em revista à residência do denunciado, foram localizadas, embaixo do colchão da cama em que ele dormia, dois saquinhos plásticos contendo várias pedras de crack (fl. 10). Ao lado dessa cama, dormia o avô do imputado, que alegou que a droga pertencia ao CLÁUDIO. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando as informações recentes dos policiais militares envolvendo o denunciado na prática do tráfico de drogas, somada à quantidade, forma de acondicionamento e alto potencial nociva das porções da substância entorpecente apreendida, adquiridas de pessoa até o momento não identificada, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 138/143), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 147), o despacho de fls. 164/168, de 19 de abril de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 210/211), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus quanto ao delito de tráfico de drogas, e a absolvição por ausência de provas da estabilidade e permanência quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 210/211), pugnou pela improcedência da ação penal, devendo o réu ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, CPP, por ausência de provas quanto a destinação dos entorpecentes, já que ficou demonstrado que a droga encontrada destinava-se ao seu consumo pessoal, pois é comum que usuário guardem em local escondido seus entorpecentes, e assim, caso não seja o entendimento anterior acolhido, que seja desclassificada a conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Quanto a eventual condenação, requer seja aplicada no mínimo legal, pugnando pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10; pelo relatório de investigação policial de fls. 37/60; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 11/13; pelo laudo químico toxicológico de fls. 110/112, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0026898) Descrição: Dois invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido petrificado Massa Bruta e/ou Quantidade: 4,31 grama(s) - Quatro gramas trinta uma centigramas. Massa Líquida: 2,12 grama(s) - Duas gramas doze centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia

em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha Willian Gomes da Silva Namura, sob o crivo do contraditório declarou que em meados de dezembro, chegou até seu conhecimento, denúncia anônima sobre tráfico de drogas no bairro e na denúncia era sobre Vitor Anacleto que morava no local próximo ao campo onde fazia a venda de drogas. Em investigações conseguiram captar várias imagens típicas de tráfico de drogas. Viram também que o vitor contava com a ajuda de Claudio, que todos os dias estava por ali, inclusive foi feito imagens dele, encontrando e entrando na casa de Vitor, saindo e entregando algo, então percebemos que ele auxiliava o Vitor. Lembra que no final de janeiro conseguiram abordar um usuário e prender o Vitor em flagrante, o Claudio não foi localizado esse dia. Concomitantemente, chegou uma ordem de serviço referente ao boletim de ocorrência que envolvia policiais militares em novembro envolvendo também Vitor e o réu Claudio, também foi encontrado crack com eles, e assim, continuaram a investigação sobre o tráfico no local. Como conseguiram prender o Vitor em flagrante, e diante das informações de que Claudio estava auxiliando na venda de entorpecentes, representou pelo mandado de buscas domiciliar em sua casa. Claudio morava com a mãe na residência, e fato que chamou a atenção foi a presença de fezes na casa e cumprindo a busca, foi encontrada quantidade de crack embaixo do colchão. Seu avô estava no quarto e indagado, disse que era tudo do Cláudio, sendo lavrada a prisão em flagrante. A primeira campana envolvendo o Vitor e o Claudio, afirma que foram muitos dias, de quinze a vinte dias de diligência. Nessas imagens, não era possível visualizar o que era passado entre Vitor e Claudio, apenas pela experiência que têm, sabem se tratar de drogas, aquele jogo rápido entre traficante e usuário. Claudio disse que era ser usuário, para consumo pessoal.

A testemunha Andrews Markus Bratifisch, sob o crivo do contraditório declarou que os fatos decorreram de cumprimento de mandado de busca e apreensão oriunda de uma investigação realizada por Willian Namura, e no cumprimento do mandado, localizamos o investigado deitado num colchão. Informado sobre o mandado de buscas, notaram que a casa estava fechada e no banheiro havia muitos dejetos pelo chão. E procurado foi encontrado dois saquinhos de crack. Indagado ao avô do acusado, ele disse pertencer ao seu neto, e Claudio afirmou que a droga era para consumo próprio. Que era apenas usuário. Disse que trabalhava para outro investigado cuidando de um cavalo por R\$ 15,00 por dia. Afirma que foram feitas imagens pelo investigador Willian, foi fácil identificar o Claudio como "cavaleiro", já que ele realmente se utilizava do cavalo para se locomover e fazer a traficância. Isso ocorreu em outra prisão num outro momento, mas não participou das diligências para captar imagens. Sabem porque o cavalo não estava com o Vitor e a informações era de que o rapaz havia fugido do local o que ensejou representação de busca e apreensão na casa do acusado. Disse que o cavalo que o Claudio cuidava, seria do próprio Vitor que foi apontado em outra investigação. Não participou de investigação anterior e não sabe se teriam imagens de Claudio com o cavalo, pois sua participação foi somente no cumprimento do mandado de buscas.

O réu Claudio Henrique da Silva, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que foi pego droga e era para seu uso. Não conhecia muito bem Vitor, porque apenas cuidava do cavalo dele. Tinha contato com ele para receber dinheiro por cuidar do cavalo, ou era na parte da tarde ou a noite.

Encerrando-se a instrução processual.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, o réu Claudio apresentou justificativas, principalmente quanto ao dinheiro recebido de Vitor, dizendo que apenas cuidava do cavalo dele, que não tinha muita proximidade com ele, e recebia o valor para cuidar do seu cavalo de tarde ou de noite, porém, nenhuma prova da sua alegação trouxe aos autos, caindo em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos.

Extraí-se do relatório de investigações de fls. 37/60, é possível visualizar a presença do réu em vários momentos, inclusive, tendo ele ingressado na casa do réu e permanecido lá dentro por certo tempo, denotando que mentiu em seu interrogatório, quando disse que apenas cuida do cavalo de Vitor e não o conhece muito bem. Quem não se conhece muito bem, não frequenta a casa da pessoa com tanto frequência.

É possível notar que Claudio também entra e sai da residência de Vitor, e na imagem captada a folha 38/39, que ao sair da residência de Vitor, onde estava sendo monitorado sem ser percebido, é possível notar que além de cumprimento a pessoa de camiseta branca, logo após entrega algo pequeno em sua mão e deixa o local.

Essa situação é indicativa sem qualquer exagero ou ilação, que o acusado também fazia o tráfico de drogas na residência de Vitor, e segundo os policiais civis, principalmente, Willian Namura, disse que fizeram diligências de campo próximo a residência de Vitor e puderam visualizar e tirar fotos das atitudes do réu e de Vitor fomentando o comércio espúrio de drogas naquela localidade.

Não é demais lembrar que depoimentos de policiais, civis ou militares e agentes penitenciários, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Confira-se:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 223086/SP DJe 02/12/2013).

“Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5ª Câmara Criminal Apelação nº 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).

Nesse ponto, “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

Em outras palavras, a versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados, não tendo sido apresentada qualquer razão para que se possa desacreditar a narrativa dos policiais. Desse modo, todas as provas colhidas em juízo corroboram a confissão do réu.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (02 porções de crack pesando 2,12 gramas), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu. Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 10, corroborado com os depoimentos dos policiais, que efetuaram diversas diligências, em dias alternado, durante aproximadamente vinte dias, captando imagens do réu e de seu comparsa, Vitor, que já foi preso, ocasião em que o réu conseguiu se evadir do cerco policial, era suficiente para demonstração da traficância.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que usuários já vinham relatando o tráfico de drogas no local, bem como vizinhos próximos, que cansado da atividade criminosa, acabam denunciando, ainda que seja, de difícil identificação, acabam por serem descobertos, e é o que aconteceu nos autos, por denúncia de usuários e vizinhos próximos, mesmo que não sejam identificados, haja vista que muitos temem por sua integridade física e por suas vidas, motivo pelo qual o fazem de forma

anônima, todavia, levando a Polícia a engendrar esforços para tentativa de confirmar a veracidade das denúncias.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos, dinheiro ou qualquer outro objeto destinado ao tráfico para a configuração do crime.

Está essas confirmações em perfeita harmonia com as demais provas dos autos.

Ora, a norma penal contida no tipo do artigo 33, traz inúmeras situações verbais que consubstanciam o crime de tráfico de drogas, uma delas, é a própria forma de guardar ou ter em depósito, tanto para si próprio ou para terceiro.

A quantidade e a diversidade de drogas, e as circunstâncias como tudo se passou e a abordagem ao acusado, evidenciam que ele guardava e tinha em depósito para si próprio e para Vitor. Os traficantes normalmente usam as pessoas, principalmente os viciados para ajuda-las a esconder as drogas para posterior reabastecimento, tudo para evitar que sejam pegos com grandes quantidades, tinha plena ciência que guardava droga.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção do agente.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as

denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, das provas produzidas são suficientes para crer que o réu efetivamente guardava e tinha em depósito as drogas na sua residência, por posterior venda a terceiros.

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de guardar e ter em depósito droga em sua residência. A solução, portanto, é a procedência da ação penal e a condenação do réu nos termos da denúncia.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua Folha de Antecedentes Criminais e Certidão Estadual de Distribuição de Processos e de Atos Infracionais de fls. 35/32, já respondeu por ato infracional e já foi apreendido, cumprindo medida socioeducativa de internação pelo grave fato antissocial de tráfico de drogas, mesmo porque mentiu em seu depoimento quando disse que nunca foi preso e nem cumpriu pena antes dos fatos narrados nestes autos, embora, enquanto menor, não cumpra pena e nem é preso, todavia, demonstra que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios, até porque desde a tenra idade, é afeiçoado à prática de tráfico de drogas entre outros crimes, agravando sua situação, pois faz do crime de tráfico de drogas o seu meio de subsistência.

Indispensável é no caso, avaliar a contemporaneidade do ato infracional com o presente processo, como prova do engajamento criminal do réu com o relacionamento com atividade criminosa ou que integre organização criminosa, vez que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fala em "não se dedique" e "não integre", ou seja, no tempo presente, dessa forma, é condizente com a atual situação do réu Cláudio, que ainda conta com apenas 19 anos, e logo após completar a maioridade, voltou a delinquir e infringir a mesma norma penal incriminadora contida no artigo 33, da referida lei, ou seja, não foi suficiente e adequada para que pudesse se ressocializar e não voltar a praticar crimes.

Nesse sentido, é a recente decisão em Embargos de Divergência em Recurso Especial sob nº 2021/0012980-3, pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudesendo a execução penal. 4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável),

que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioria penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena. 5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.” (ERESP 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021).

No mesmo sentido já vinha decidindo acerca da matéria a 5ª Turma do S.T.J.: “Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no Recurso Especial n. 1873094/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Muito embora, o Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu unanimemente acerca da matéria, somente pelas Turmas daquela Corte, que pela 1ª Turma em decisão monocrática do Min. Luiz Fux, entende pelo afastamento da minorante do §4º, do artigo 33, da Lei em comento, senão vejamos o precedente abaixo colacionado: [...] Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão de a paciente se dedicar a atividade criminosa, o que restou demonstrado do amplo conjunto probatório dos autos. Quanto ao tema, o Tribunal a quo assentou que “o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de drogas, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas”. Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. [...] Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. (RHC n. 180.509, Rel. Ministro Luiz Fux, monoc., DJe 6/2/2020). Portanto, os atos infracionais podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa, o que ficou amplamente demonstrado nos autos. Nesse diapasão, é de se reconhecer que a razão de ser do chamado “tráfico privilegiado”, consiste em punir com menor severidade aquela que vem a ser surpreendido pela primeira e única vez, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida.

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, todavia o processo servirá para anotação da sua reincidência, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda etapa, ausentes quaisquer agravantes, todavia, presente a atenuante genérica da menoridade relativa do réu, que possuía menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, conforme dispõe o artigo 65, inciso I, do Código Penal, que reduz a pena na fração de 1/6 (um sexto), voltando a pena ao seu patamar mínimo. Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos

narrados na denúncia.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/06, o que não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, se dedica integralmente ao tráfico de drogas, fazendo do crime seu estilo de vida, conforme dito por ele mesmo em seu interrogatório, inclusive deixou claro que sua convivente também encontra-se presa pelo mesmo crime, denotando-se que outra forma de cumprimento de pena seria inócua.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, RG 58437935, CPF 488.429.008-93, mãe SANDRA REGINA DA SILVA, Nascido/Nascida em 22/03/2003, de cor Pardo, natural de Presidente Prudente - SP, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva dos réus nestes autos e por terem eles respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

INCONTINENTE, encaminhe-se cópia desta sentença para instruir autos de Habeas Corpus nº 2006062-56.2022.8.26.0000, RELATOR DESEMBARGADOR: ROBERTO PORTO: PACIENTE: CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA, em trâmite perante a 4ª Câmara de Direito Criminal.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA